

Acerca de la cuantificación del daño punitivo

El art. 52 bis de la ley 24.240, incorporado por la ley 26.361 (B.O. del 7-IV-2008), establece que: *"Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley".*

La determinación de la cuantía por esta multa civil no ha estado exenta de controversias. A grandes rasgos se imponen dos posturas predominantes, a saber, aquellas que propugnan el uso de una fórmula matemática para su cuantificación, frente a los que sostienen que el prudente arbitrio judicial resulta suficiente para su tal tarea.

Conviene poner de manifiesto que, sin importar en que postura se enrole el Juez, siempre será el criterio de éste el que ponga el monto final, pues la fórmula matemática lo que hace es facilitar la fundamentación del monto elegido, una vez aceptado el algoritmo propuesto. El sentenciante no tiene que dar los motivos por los cuales considera ese monto como “justo”, sino que debe argumentar acerca de la elección de la fórmula. No cabe duda que es más simple utilizar el monto que arrojan las operaciones aritméticas propuestas y aceptadas en jurisprudencia anterior, permitiendo de este modo desplazar la responsabilidad del juzgador hacia la fórmula, obligando a quien recurre la sentencia a no cuestionar el criterio del Juez más que en la elección de la fórmula (que suele encontrar sustento en la jurisprudencia reciente). Por lo que aparece una duda: ¿Cómo se cuestiona una fórmula? Estimo que el camino deberá ser desmembrarla y considerar cada uno de los parámetros que la componen, aunque siempre resulta más simple atacar el resultado final al que se arriba y contrastarlo con la realidad.

En lo que refiere al daño punitivo ha cobrado notoriedad la fórmula ideada por el jurista bahiense Irigoyen Testa[1], que se expresa de la siguiente forma:

$$D = C \times [(1 - P_c) / (P_c \times P_d)]$$

Donde “C” es la cuantía del daño provocado al consumidor

“P_c” es la probabilidad de ser condenado por la indemnización compensatoria de los daños provocados

“P_d”, la probabilidad de ser condenado por daños punitivos.

Como se puede observar a primera vista, surgen dos problemas de cierta gravedad. Por un lado, el punto de partida es el daño provocado al consumidor, cuando específicamente la norma impone que la cuantificación “*se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan*”. Por otro lado, las probabilidades, tanto de ser condenado por la indemnización compensatoria de los daños provocados, como la probabilidad de ser condenado por daños punitivos, no hay forma de determinarla ni siquiera en forma aproximada. Volvemos así al arbitrio judicial, sólo que enmascarado en el aspecto de una fórmula matemática.

En los autos “Castelli, María Cecilia c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ Nulidad del acto jurídico”, (C 119562 del 17/10/2018), en su voto el Dr. Pettigiani enumera ciertos criterios que deberían considerarse al momento de determinar la cuantía del daño punitivo. La parte pertinente del fallo dice: “*En tal entendimiento, por un lado, la valuación de la condenación punitiva puede considerar la índole y gravedad de la falta cometida por el agente dañador en su relación con los derechos conculcados y el perjuicio resultante de la infracción; así como la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización; la repercusión social de su conducta o del daño ocasionado (carácter antisocial); la naturaleza y grado de desequilibrio de la relación entre el dañador y la víctima; la existencia de otros damnificados con derecho a reclamación (pluralidad de víctimas); la cuantía del beneficio o ahorro procurado u obtenido por el agente dañoso con el ilícito (rédito); su situación o solvencia económica (carácter irrisorio); su posición en el mercado (hegemonía, estandarización); el número y nivel de empleados involucrados en la conducta (atribución y fidelidad); la posibilidad que haya tenido el dañador de conocer el peligro y evitar el daño (indiferencia, ligereza, imprevisión); el grado de su intencionalidad (negligencia o dolo); la existencia de antecedentes de sanciones similares impuestas al responsable del daño (reincidencia) o a similares proveedores de bienes o servicios; la posibilidad de reiteración de la conducta reprochada (o similares) si no mediara condena pecuniaria; la actitud del agente dañador con posterioridad al hecho que motiva la pena (mitigación y no agravamiento del daño); la posible existencia de otras sanciones penales o administrativas (en cuanto la sumatoria pueda conducir a una sanción excesiva o irrazonable); la existencia de precedentes judiciales (homogeneidad en los montos de condena); y las diversas funciones que el instituto está destinado a cumplir (sancionatoria, disuasiva, ejemplificadora, preventiva de futuros daños, etc.; conf. XVII y XXI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, 1999 y 2007 respectivamente; Proyecto de Código Civil y Comercial, 1998; análogamente, art. 49, ley 24.240).*”

Como podrá observarse, se proponen varios factores que deberían considerarse al momento de cuantificar la suma a aplicar por daño punitivo, arribando con ello a un monto más adecuado para el caso en particular, quitando la abstracción propuesta por la fórmula tratada más arriba.

Se ha propuesto una nueva fórmula, con ansias de aportar mayor precisión al cálculo, pero incluyendo variables propias del caso a dilucidar, lo que la acercan a una solución más objetivamente adecuada y que considera algunos de los puntos enumerados por el Dr. Pettigiani.

La fórmula, propuesta por el Dr. Arias Cáu y la Dra. Nasif[2], es la siguiente:

$$D.P.= \{CB [(a/b/1000) + (cd)]\} /e * f$$

Donde: D.P. es el daño punitivo a determinar

CB es la canasta básica, valor que toman como punto de partida para los consumidores

a es el perjuicio ocasionado (daño indemnizable)

b es la posición en el mercado (3 para pequeñas empresas, 2 para medianas y 1 para grandes)

c es la cuantía del beneficio (1 leve, 2 moderado, 3 alto)

d es el grado de intencionalidad (1 bajo, 2 moderado, 3 alto)

e es la gravedad de los riesgos (3 sin riesgos, 2 bajo, 1 moderado, 0 alto)

f es la reincidencia (1 sin reincidencia, 2 esporádica, 3 frecuente)

Para ejemplificar imaginemos un caso donde una empresa de electricidad incumplió dejando sin servicio a una familia durante unos días, y se fija la indemnización por distintos rubros en un total de \$ 100.000. Para la canasta básica los autores de la fórmula proponen el uso de la canasta básica total (hoy \$ 64.000) frente a la canasta básica alimentaria (hoy \$ 24.000). El perjuicio ocasionado (a) es de 100.000, estamos frente a una gran empresa (b), la cuantía del beneficio es leve (c), el grado de intencionalidad es bajo (d), la gravedad pongamos que es moderada (e) y la reincidencia será la más baja (f) (suponiendo que no sea algo que suela pasar).

Así la fórmula

$$D.P.= \{CB [(a/b/1000) + (cd)]\} /e * f$$

Se convierte en

$$D.P.= \{64.000 [(100.000/1/1000) + (11)]\} /1 * 1$$

Entonces

$$D.P.= \{64.000 [100 + 1] /1 * 1$$

$$D.P = (64.000 \cdot 101) / 1$$

$$D.P = 6.646.000$$

Esta fórmula, si bien sensiblemente más precisa y abarcativa que la desarrollada en primer término, puede ser objeto de algunas críticas. ¿Quién decide el límite entre una empresa mediana y grande? ¿Es lo mismo si esa empresa es una biblioteca comunitaria que un supermercado? ¿De dónde sale la variable “1.000” entre los términos b y c? ¿Puede modificarse para alterar el resultado? ¿Si el riesgo es grave no importa la reincidencia?

Pero la pregunta fundamental que surge contra cualquier de las fórmulas matemáticas ofrecidas es otra: ¿Necesitamos una fórmula para determinar el daño punitivo? Confiamos en los jueces para saber si hay o no relación de consumo, si hay o no responsabilidad o relación causal, pero ¿no confiamos para determinar la medida de la indemnización?

Conviene recordar que la jurisprudencia de EEUU ya lo ha intentado[3]. En momentos en que las indemnizaciones por daño punitivo se descontrolaron (run wild decían en State Farm Mut. Aut. Ins. Co. v. Campbell, 538 U.S. 408, 429 de 2003), pretendieron fijar una ratio que ate el daño patrimonial o las costas del proceso con el daño punitivo. Esa ratio rápidamente se vio alterada, sosteniendo que si el monto reclamado era alto, bien el daño punitivo podía tener una relación de 1:1, pero que si lo que se reclamaba era menor, bien podría llegar a las dos cifras (ratio 1:10 o más). Finalmente, se dejó de lado, pues se consideró que la forma de determinar el monto era algo que correspondía a cada Estado, y no podía el poder central inmiscuirse, sin perjuicio de hacer notar la inutilidad de intentar buscar un criterio uniforme para causas con tan importantes diferencias.

Con gran tino el legislador determinó que el daño punitivo “*se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan*”, tornando inaplicable cualquier fórmula, ya que todas toman como punto variable o de partida, el monto de las otras indemnizaciones otorgadas.

Los intentos de recurrir a otras variables, solo arrojan más confusión e intentan normalizar situaciones intrínsecamente dispares. Así, parece que confiar en el arbitrio judicial es la opción más viable, al menos de momento, y la forma en que la decisión sea fundada dará pie para el análisis y ataque por parte de los litigantes en caso de no estar de acuerdo con la decisión.

Volviendo al voto del Dr. Pettigiani en el fallo Castelli, se impone como una buena práctica analizar los puntos que detalla, pues entiendo que ello sería una adecuada justificación a la decisión final, incluso detallar uno por uno a la luz del caso que se juzga, aparece como argumentación suficiente y otorga claridad a los litigantes, a la sociedad y al resto de los organismos que puedan rever la resolución.

Por otro lado, sería sumamente útil contar con un registro de sentencias que hayan aplicado esta multa civil, y que permita al juzgador, pero también a las partes, conocer los montos que se han determinado en situaciones similares. Esa aparece hoy como la mejor opción para brindar seguridad jurídica y coherencia al sistema, que entiendo es la función pretendida por quienes proponen las fórmulas matemáticas. Bien podría tratarse de un registro provincial y, de toda la base de datos que posee la Suprema Corte de la Provincia, se identifiquen aquellas sentencias que hayan aplicado daños punitivos, accesible al público para su consulta y para los órganos jurisdiccionales, por los mismos medios que se puede consultar el resto de la jurisprudencia.

En consecuencia, entiendo que si bien han sido loables los intentos por realizar una fórmula matemática que determine la cuantía de la multa civil a aplicar al proveedor de servicios que incumple sus obligaciones, dichos esfuerzos han resultado poco útiles, y difícilmente puedan lograr su objetivo de manera generalizada, por lo que la creación de un registro centralizado de libre consulta de sentencias con aplicación de daño punitivo, aparece como más acertado actualmente, sirviendo aquellos antecedentes como una guía para que el juzgador, considerando el resto de las pautas delineadas por el Dr. Pettigiani en el fallo Castelli, pueda fundar adecuadamente el monto de condena al que arribe.